

罪相比，在网络上开设赌博的犯罪行为认定难度也越来越大。本案的被告人建立的并非通常意义上的赌博网站，他们不接受投注、不担任代理，甚至不直接组织赌博活动。但人民法院坚持源头打击，根据所架设平台的基本属性、各被告人的行为、分成金额、资金流水等，准确认定事实及各被告人的地位、作用等，落实宽严相济刑事政策，对被告人进行了精准打击。公众网络“私域”空间不是法外之地，赌博犯罪无论如何变身隐形，都逃不过被依法惩处的下场。

编写人：四川天府新区人民法院 邓双双廖礼红

利用网络娱乐平台开设房间组织赌博的 行为性质及犯罪数额认定

——赵某某等开设赌场案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省保定市中级人民法院(2023)冀06刑终794号刑事判决书

2. 案由：开设赌场罪

【基本案情】

2019年1月至2022年2月，被告人赵某某先后伙同张某(已判刑)、杨某、冉某(已判刑)等人为牟利，在手机上下载“某麻将”软件，组建用于赌博的亲友圈，分别拉微信好友进亲友圈以打麻将的方式进行赌博。赵某某等人分别从“某麻将客服”处低价购买房卡，为参赌人员开设房间，每局赵某某或其他人抽取房间费4元，参赌人员最后按赢取的积分计算输赢，1分按1元计算，赌资、房间费通过微信支付的方式进行结算。

赵某某违法所得共计30889元，购买房卡支付某客服资金19889元。被告人赵某某劝说、陪同王某到公安局投案，到案后如实供述其与同案犯张某共同犯罪事实。

【案件焦点】

1. 在非赌博网站开设房间组织赌博是否构成开设赌场罪；2. 组织赌博的行为人购买房卡的支出是否应从犯罪数额中予以扣除。

【法院裁判要旨】

河北省曲阳县人民法院经审理认为：被告人赵某某为牟利与他人共同组建用于赌博的微信亲友圈，通过下载的“某麻将”软件，购买房卡开设房间，拉微信好友进入房间以打麻将的方式进行赌博，从中抽头渔利，构成开设赌场罪。赵某某劝说、陪同同案犯王某自首，系立功，依法从轻处罚；自愿认罪，酌情从轻处罚；到案后如实供述与张某开设赌场犯罪事实，可以从轻处罚。赵某某抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，应判处五年以上有期徒刑。

河北省曲阳县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条规定，认定被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元；依法追缴被告人赵某某违法所得人民币30889元。

一审宣判后，赵某某提出上诉。

河北省保定市中级人民法院经审理认为：上诉人赵某某伙同他人以营利为目的，利用网络平台作为开设赌场的工具，使参赌人员通过该网络平台进行赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。

关于赵某某的行为性质。“某麻将”软件为网络娱乐平台，赵某某组建亲友圈，在该娱乐平台创建房间，并组织招揽亲友圈的人员参与赌博，抽取房间费，赵某某的行为虽非字面意思上的建立赌博网站担任代理并接受投注，但其

利用“某软件”这一合法网络平台的游戏规则，抽房间费，此时俨然已具有赌博功能，合法平台具有了赌博网站性质，其在实质上便是建立了赌博网站。

关于赵某某抽头渔利的数额。赵某某抽头渔利的数额有其在公安机关的供述以及鉴定报告等证据相互印证，可以认定其犯罪数额为30889元。赵某某购买房卡并支付房费是其实施开设赌场行为的必要条件，其支付的犯罪成本具有利用可能性，能够帮助其实现预期的交易目的，系其为实现犯罪既遂所必须付出的代价，不应予以扣除。

综上，原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当。河北省保定市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系利用网络进行的赌博犯罪行为，从全案来看，被告人的行为同在物理空间开设赌场及司法解释规定的典型的网络开设赌场均存在较大差异，争议焦点在于在非赌博网站开设房间组织赌博是否构成开设赌场罪，以及购买房卡的支出是否应从犯罪所得中予以扣除。

一、在非赌博网站开设房间组织赌博构成开设赌场罪

开设赌场侵犯的是正常的社会管理秩序和社会风尚，客观方面表现为具有为赌博提供场所、赌具、筹码等，设定赌博方式、规则，控制、组织赌博的行为，主观方面需具有营利的故意。传统的赌博场所一般是房屋、场馆等实际空间，赌具、筹码也都看得见、摸得着，当前更广泛的犯罪形式是利用网络开设虚拟赌场进行犯罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，均属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：(1)建立赌博网站并接受投注的；(2)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；(3)为赌博网站担任代理并接受投注的；(4)参与赌博网站利润分成的。

上述意见明确了建立赌博网站按开设赌场定罪处罚的裁判规则，但本案利用普通网站组织人员进行赌博活动是否构成开设赌场罪并未明确。此时，应该结合涉案行为是否具备开设赌场罪的实质特征进行判定，具体而言：

(1)开设赌场应当具有经营性。开设赌场罪的主观目的限定为以营利为目的，通常表现为通过组织或管理赌博行为，以抽头渔利等方式直接从组织或管理赌博活动中获利。本案行为人以抽取房间费的形式非法获利，符合经营性特征。(2)开设赌场应当具有组织性。开设赌场罪中，为了招揽赌客，将零散的赌博行为转化为有组织性的赌博活动，赌场经营者一般会形成相对明确的组织架构和人员分工。本案中，行为人赵某某组建用于赌博的亲友圈，发展王某等人为“小队长”，“小队长”去拉人赌博，具备了一定的组织性。(3)开设赌场应当具有控制性。经营者对赌博活动的控制性，主要体现在由开设赌场的人决定在何时何地开展赌博，且赌场经营者参与制定赌博输赢规则和抽成比例等结算规则。本案中，赵某某等人在网站为参赌人员开设房间，提供赌博场所，制定计分制的输赢规则和房间费抽成比例以及结算规则，具备了控制性特征。(4)开设赌场应当具有规模性。开设赌场往往具有一定的规模，以赌场的持续经营来招揽赌客，赌场会向不特定人员开放。本案中，赵某某等人自2019年至2022年，纠集多人在网站开设房间，拉不特定的微信好友进行赌博，赌场持续运营，具备了规模性。

综上，被告人利用赌博网站提供的虚拟房间，支付房卡(房间费用)后，自己招揽人员进入房间，根据网站提供的软件、规则组织赌博，参赌人员向被告支付房间费用，被告人赚取房卡差价、通过社交软件为参赌人员进行赌资结算并抽头，该行为虽然与司法解释规定的传统网络开设赌场案件中为赌博网站担任代理、参与利润分成、提供服务收取服务费等行为不同，但为他人赌博提供了场所、平台、设备，并从中渔利，应视为开设赌场的行为，这一实质内核既适用于物理空间，也适用于网络空间，因此其行为实质仍是现实社会中开设赌场行为的虚拟化，具有专门场所、面向不特定人群、专设赌博项目、提供资金结算、固定盈利方式等要素，故应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，以开设赌场罪定罪处罚。

一、妨害社会管理秩序罪 99

二、组织赌博的行为人购买房卡的支出不应从犯罪数额中予以扣除

在利用合法娱乐平台创建房间用于赌博类开设赌场犯罪的违法所得数

额认定上，通常来说，“违法所得”是指行为人在违法犯罪活动中违法所得